Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 5ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810381

Processo nº 0024949-22.2021.8.17.2001

AUTOR: CARLOS EDUARDO GUERRA COELHO

REU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Visto, etc.

Carlos Eduardo Guerra Coêlho, através de advogado regularmente habilitado, ajuizou a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA *INAUDITA ALTERA PARS*** em face de **Bradesco SAÚDE S/A,** igualmente qualificado, pelos fatos a seguir narrados.

Em apertada síntese, alega a parte autora que contratou plano de saúde BRADESCO SAÚDE TOP NACIONAL Q CA 6 junto à empresa Ré.

Aduz que fora diagnosticado com Miastenia Gravis (CID G70.0) e que necessita de infusão de Rituximab, medicação primordial para conter o avanço da doença que já se encontra em ritmo de agravamento acelerado.

Afirma que a operadora de saúde teria negado o referido tratamento, sob o argumento de que este não se encontraria abrigado em rol de procedimentos descritos na Resolução Normativa nº 428, da Agência Nacional de Saúde.

Requereu a concessão de Tutela de Urgência para que a ré seja compelida fornecer a imediata aplicação do medicamento RITUXIMAB, na dose de 375 mg/m2 (750 mg), sendo 2 infusões separadas por 15 dias, com repetição a cada 6 meses, conforme laudo médico.

Por fim, requereu a confirmação da tutela em sentença, além de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Anexou, dentre outros documentos, laudo médico indicando o tratamento a ser perseguido, conforme ID 78418630.

Tutela deferida concedendo prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação.

Embargos de Declaração requerendo dilação de prazo para cumprimento da tutela.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação aduzindo que não procedeu com qualquer ilegalidade, tendo em vista que não há cobertura contratual para tratamento em espécie, tampouco, previsão normativa constante do rol da ANS.

Ante a inexistência de conduta ativa ou passiva, por parte da ré, não há que se falar em dever de reparação moral.

Requereu a improcedência da ação em todos os seus termos.

Anexou aos autos documentos que entendera pertinentes.

Réplica acostada aos autos, reafirmando os termos da inicial.

É relatório. Passa-se ao julgamento.

Ab initio, caracterizada hipótese de incidência do teor do disposto no artigo 355, inciso I, do Novo Estatuto de Ritos, que autoriza o julgamento antecipado da lide.

Antes de apreciarmos as nuances do caso concreto, há de se ressaltar que há pedido do autor para que seja invertido o ônus da prova não apreciado na instrução do feito, não podendo haver o deferimento do pedido em tela na constituição da sentença, sob pena de nulidade processual.

Nesse sentido, vale colacionar o seguinte julgado:

> APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE DO PROCESSO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO.
>
> - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a questão da inversão do ônus da prova trata-se **de regra de instrução**, motivo pelo qual, após decidir sobre tal requerimento, "deve o magistrado possibilitar que as partes voltem a requerê-las, agora conhecendo o seu ônus, para que possam melhor se conduzir no processo, sob pena de cerceamento de defesa" (AgRg no REsp 1.520.987/GO).
> - Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais quando, não oportunizado à parte que produza as provas necessárias à comprovação do direito alegado, profere a decisão com fundamento na ausência de prova dos fatos constitutivos.
> - Ausente a adequada instrução processual, o julgamento do mérito caracterizaria cerceamento de defesa para a parte interessada, inviabilizando o imediato julgamento nessa instância recursal.
> - Preliminar de nulidade do processo acolhida, de ofício, prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Apelação Cível

1.0879.14.000883-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/0020, publicação da súmula em 09/06/2020)

Nesse aspecto, o caso em tela não parece indicar que deva haver aplicação da inversão do ônus da prova do art. 6º, inc. VIII, do CDC, pois a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, cabendo ao julgador analisar a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência processual, incluindo-se aqui a dificuldade em produzir a prova necessária ao êxito na demanda.

Nesse sentido, vale colacionar o seguinte julgado:

> SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO - INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -DESCABIMENTO, POIS NÃO É AUTOMÁTICA E TAMPOUCO OBRIGATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.
>
> A chamada inversão do ônus da prova não é automática. Ela depende de circunstâncias concretas que devem ser apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor".
>
> (TJ-SP - AI: 22737618520198260000 SP 2273761-85.2019.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 19/03/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2020).

Assim, considerando que a análise dos autos está afeta a observância de documentos, entendendo que aqueles constantes dos autos são suficientes para uma verificação robusta do feito, sem olvidar que não houve qualquer relato de dificuldade na produção da referida prova documental.

Desta forma, entendo que a regulação da atividade probatória se dará nos moldes do que prevê o artigo 373, do Código de Processo Civil.

É preciso pontuar, antes de passarmos à análise dos autos, que parte autora apresentou Embargos de Declaração, ante o exíguo prazo concedido para o cumprimento da tutela de urgência.

Entendo que o pedido formulado não encontra abrigo nas hipóteses previstas e autorizativas dos aclaratórios, cujos argumentos aqui externados, por si sós, já indicaria, sequer, o conhecimento destes.

Contudo, entendo que a finalidade da pretensão formulada nos aclaratórios, qual seja, a dilação de prazo foi alcançada para o cumprimento da tutela. Isto porque, não há nos autos indicativo de descumprimento da referida tutela, logo, ao meu sentir, resta prejudicada qualquer análise mais profunda sobre o pedido de dilação de prazo formulado através de Embargos de Declaração.

Pois bem. Cinge-se à controvérsia em verificar se a negativa de cobertura do tratamento prescrito pela médica assistente encontra-se plasmada no ordenamento jurídico brasileiro e nas normas que regulam a matéria.

O primeiro esclarecimento a ser feito é que a ANS é uma autarquia especial, criada para regular o mercado onde opera a instituição demandada. Assim, toda e qualquer previsão de cobertura ali prevista tem por escopo indicar elementos mínimos de cobertura perante as operadoras de saúde, sem os quais estas não poderiam, sequer, ofertar seus produtos no mercado de consumo**.**

Assim, aquele rol de cobertura previsto em Resolução não tem o condão de influenciar nas relações privadas existentes entre o usuário do plano de saúde e o médico assistente.

Ao contratar o produto ofertado pelo plano de saúde, o consumidor o faz livre de qualquer patologia notória. Aliás, a própria preexistência de doenças como argumento de negativa de cobertura há muito vêm sofrendo mitigação. Afinal, na ponderação entre os princípios que permeiam o rigor do cumprimento integral do contrato e aqueles que materializam o Direito Fundamental à Saúde, resta inegável que estes deverão prevalecer.

Incontroverso o contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes. Como também a prescrição e a negativa do medicamento para o tratamento indicado pela médica assistente. Prova disso é que o autor somente recebera o devido tratamento após a concessão da tutela de urgência.

Observa-se *in casu* que o procedimento recomendado é necessário e fundamental para dar prosseguimento ao tratamento do autor, sendo este imprescindível para o completo restabelecimento da sua saúde.

Impende consignar que é irrelevante a ausência de previsão deste procedimento no rol da ANS, porquanto presumida a imprescindibilidade do procedimento, exame ou medicamento prescritos pelo médico.

Desta forma, restando evidente nos autos que o médico assistente prescreveu o tratamento a ser seguido, de rigor, seu integral cumprimento.

Nesse sentido, colacionem-se os seguintes julgados:

> DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. **NEGATIVA DE MEDICAMENTO**. PACIENTE COM CÂNCER. **NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO XELODA. RECUSA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANOS MORIS CONFIGURADOS**. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO. No caso dos autos, verifica-se que o médico assistente atestou que o autor/recorrido é portador de NEOPLASIA DE PÂNCREAS, tendo realizado intervenção cirúrgica, sendo-lhe prescrito tratamento antineoplásico com três medicações diversas, indicando o tratamento com XELODA utilizado para destruir neoplasmas ou células malignas e tem a finalidade de evitar ou inibir o crescimento e a disseminação de tumores (laudo fls.24) Ademais, a medicação em questão vem sendo amplamente prescrita por profissionais médicos, configurando, inclusive, seu fornecimento objeto de diversas demandas. Igualmente, não assiste razão à insurgência contra a condenação da recorrente nos danos morais, visto que esta e. Corte tem entendimento no sentido de que a recusa indevida da

operadora de saúde no fornecimento do tratamento pleiteado pode dar ensejo à indenização por dano moral (inteligência da Súmula 035 do TJPE). Deste modo, a seguradora deve responder pelos danos morais causados à parte autora, de acordo com o disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do CC, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, revelada, no caso dos autos, em razão da negativa injustificada da cobertura ao tratamento solicitado, procedimento este flagrantemente abusivo, por meio do qual a demandada assumiu o risco de causar lesão à parte autora, mesmo que de ordem extrapatrimonial. Frise-se, ainda, que incide na hipótese a aplicação do art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

(Apelação Cível 530170-60015422-16.2016.8.17.1130, Rel. Antônio Fernando de Araújo Martins, 6ª Câmara Cível, julgado em 25/05/2021, DJe 18/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE OVÁRIO. **NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS (BEVACIZUMABE, CARBOPLATINA E GENCITABINA). USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS**. 1.O art. 12 da Lei 9.656/1998 considera imperativo o fornecimento de medicamento antineoplásico, independentemente de internação hospitalar ou tratamento ambulatorial de urgência e de emergência. 2. De acordo com a orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.712.163/SP e REsp nº 1.726.563/SP (Tema 990), as operadoras de plano de saúde estão obrigadas a fornecer medicamento medicamentos indicados pelo médico responsável, após o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 3. "É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão" (AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,

julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). 4 A negativa indevida de cobertura de procedimento essencial à garantia da saúde do segurado agrava a situação psicológica e gera aflição e angústia que ultrapassam o patamar de mero dissabor, caracterizando o dano moral indenizável. Diante das nuances do caso concreto, o arbitramento da verba indenizatória no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tal como fixado pelo juízo de primeira instância, não desbordou do razoável, tendo em vista a dupla finalidade da indenização: servir como compensação e como desestímulo à prática ilícita por meio da punição. 5. Recurso a que se nega provimento.

(Apelação Cível 361118-50175816-28.2012.8.17.0001, Rel. José Fernandes de Lemos, 5ª Câmara Cível, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021)

Feitas tais considerações, é preciso verifica se houve dano moral a ser indenizado.

Pois bem. Sobre a existência de dano moral a ser indenizado é imperioso ponderar que ao tratar de danos em geral, a doutrina concebe a distinção de três categorias distintas, a saber: a) são patrimoniais os prejuízos de ordem econômica causados por violações a bens materiais ou imateriais de seu acervo; b) pessoais, os danos relativos ao próprio ente em si, ou sem suas manifestações sociais, como, por exemplo, as lesões ao corpo, ou a parte do corpo (componentes físicos), ou ao psiquismo (componentes intrínsecos da personalidade), como a liberdade, a imagem, a intimidade; c) **morais, o relativos a atributos valorativos, ou virtudes, da pessoa como ente sociais, ou seja, integrada à sociedade, vale dizer, dos elementos que a individualizam como ser, de que se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto**. (BITTAR, Op.cit., p. 35)

No RECURSO ESPECIAL Nº 1.637.629 - PE (2014/0019878-8), a Ministra Nancy Andrighi assim se posicionou:

"Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras

palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade".

De outro lado, na lição abalizada de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

A lesão a bem personalíssimo, contudo, para caracterizar o dano moral, deve revestir-se de gravidade que, segundo ANTUNES VARELA, citado por Sérgio Cavalieri Filho, “há de medir-se por um padrão objetivo e não à luz de fatores subjetivos”.

No caso concreto, entendo que o dano moral subsiste a partir do momento que o plano de saúde nega tratamento devido e prescrito pela médica assistente, causando grave temor na parte autora ao pôr em risco a continuidade do tratamento.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos elencados na petição inicial, extinguindo, em consequência, o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, **tornando definitiva a tutela provisória de urgência concedida**, para o fim de compelir a ré a manter o fornecimento do medicamento, nos moldes do que fora prescrito pela médica assistente, em laudo de ID 78418630, sob pena de imposição de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Condeno a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de **R$ 6.000,00 (seis mil reais),** com correção monetária pelo ENCOGE a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante a sucumbência da ré, entendo por condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.

Recife, 31 de agosto de 2021.

Janduhy Finizola

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JANDUHY FINIZOLA DA CUNHA FILHO
31/08/2021 13:06:16
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 87394479

21083113061575300000085548549

IMPRIMIR GERAR PDF